

1505991-41.2019.8.26.0510

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DURVAL JOSE DE MORAES LEME

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/02/2022

... da concessão de graça e anistia e de indulto ao tráfico de entorpecentes, "os Decretos Presidenciais nº 6706/08 e 7049/09 beneficiaram os condenados pelo tráfico de entorpecentes privilegiado com o indulto, o que demonstra que os mencionados textos normativos inclinaram-se na corrente doutrinária de que o tráfico privilegiado não é hediondo".

Tal entendimento ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

1ª Vara Criminal

Avenida 5 nº 545, Rio Claro-SP - cep 13500-380

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1505991-41.2019.8.26.0510 -

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505991-41.2019.8.26.0510 - 2019/001344

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jose Thiago de Jesus dos Santos

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. DURVAL JOSE DE MORAES LEME

Vistos.

JOSÉ THIAGO DE JESUS DOS SANTOS, qualificado no inquérito, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, Consta dos inclusos autos do inquérito policial que no dia 21 de novembro de 2.019, por volta das 10:30 horas, na Avenida M-37, nº 2417, Jardim das Flores, nesta Comarca, com intuito mercantil, para consumo de terceiros, vendeu 05 (cinco) invólucros contendo a substância entorpecente denominada cocaína, na forma de crack, trazia consigo 03 (três) invólucros contendo a mesma substância entorpecente, também na forma de crack, totalizando com aqueles outros peso líquido aproximado de 1,6 gramas, e ainda guardava e tinha em depósito outros 02 (dois) invólucros plásticos contendo a substância entorpecente denominada tetrahidrocannabinol, totalizando peso líquido aproximado de 4,6 gramas, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 11 e laudo de constatação de fls. 13/15, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Regularmente notificado, seguiu-se oferecimento de defesa preliminar em favor do

acusado, sendo posteriormente recebida a denúncia no dia 20 de setembro de 2021. Em instrução, foram ouvidas duas testemunhas de acusação, seguindo-se o interrogatório do acusado.

Em alegações finais, a ilustre Representante do Ministério Público, à vista da prova produzida, requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia, com fixação da pena-base no mínimo legal, possibilitando-se a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, fixado o regime aberto.

Já ilustre Defensora Pública inicialmente pugnou pelo reconhecimento do princípio da insignificância, dada a diminuta quantidade de entorpecente apreendida, com a consequente absolvição, ou ainda diante do reconhecimento da excludente da inexigibilidade de conduta diversa, tudo nos termos do artigo 386, incisos III e VI, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu seja a pena-base fixada no mínimo legal, possibilitando-se a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a fixação de regime prisional inicial aberto, facultando-se a interposição de recurso em liberdade, com o restabelecimento da liberdade provisória anteriormente concedida ao acusado.

Em síntese, o RELATÓRIO.

DECIDO.

Procede a pretensão acusatória.

Atribui-se ao acusado a prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. as disposições da Lei nº 8.072/90, assim porque vendeu a terceiro, trazia consigo e ainda guardava e tinha depósito, com intuito mercantil, para consumo de terceiros, o entorpecente indicado na denúncia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Conquanto incontroversa, a materialidade do delito vem comprovada pelo que exposto no laudo de exame químico-toxicológico encartado as fls. 60/61, com resultado positivo para cocaína, identificando-se também em parte da substância apreendida o elemento tetraidrocanabinol, responsável pelos efeitos estupefacientes da maconha. Sustenta-se que se cuida de apreensão de diminuta quantidade de entorpecente, incidindo o princípio da insignificância, a afastar a materialidade do delito.

No entanto, respeitado o entendimento exposto, conquanto não expressiva a quantidade de entorpecente apreendida, não se tem possibilitado a incidência do princípio da insignificância no delito de tráfico de entorpecentes, dada a natureza do bem juridicamente protegido, consistente na segurança e saúde pública, tanto mais quando se verifica que esta prática é até mesmo considerada como equiparada a outros delitos de natureza hedionda.

A propósito: "CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício. 2. O reconhecimento da atipicidade da conduta delitativa com fundamento no princípio da insignificância não é admissível em relação ao crime de tráfico ilícito de drogas, pois trata-se de crime de perigo abstrato, no qual os objetos jurídicos tutelados são a segurança pública e a paz social, sendo irrelevante a quantidade da droga apreendida.

Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido. (HC 318.936/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 09/11/2015)".

De outra parte, renovada a venia, também não se entende esteja o acusado acobertado da causa excludente da inexigibilidade de conduta diversa, ao argumento de que estaria realizando o comércio ilícito, premido pelos efeitos da condição de usuário. É que, não estando afastada a capacidade de pleno entendimento acerca da conduta ilícita, evidentemente haveria conduta diversa a ser perseguida pelo acusado, com reconhecimento, inclusive, de que chegou já a se submeter a tratamento por conta da drogadição, além da possibilidade de eleger outras condutas, à satisfação daquela condição de usuário, que não importasse na realização do tráfico

ilícito de entorpecentes.

E a não se dizer isolada, a confissão externada pelo acusado foi amparada pela prova oral produzida.

De fato, ouvido em Juízo o acusado admitiu que na ocasião dos fatos, embora tivesse realizando atividades laborativas eventuais, e a fim de obter entorpecente mais rapidamente, destinado ao próprio uso, realmente foi surpreendido logo após ter vendido as cinco porções de crack a um indivíduo, pelo valor de cinquenta reais, em seguida sendo abordado por policiais civis.

Os Policiais Civis Lucas e Érika, a sua vez, confirmaram que na ocasião dos fatos estavam passando pelo local indicado na denúncia, conhecido ponto de venda de entorpecente, quando avistaram o acusado entregando alguma coisa a um terceiro, em situação sugestiva do tráfico de entorpecentes. Em razão disto, foi ele abordado, apreendendo-se com ele três porções de crack, além da quantia de cinquenta e cinco reais em dinheiro. Com o terceiro seguiu-se a apreensão de cinco porções de crack, que recebera momentos antes do acusado, confirmando a aquisição pelo valor de cinquenta reais. Além do entorpecente apreendido com o acusado, encontraram ainda ao lado duas porções de maconha, que também reconheceu como sendo dele.

Como se vê, a confissão externada pelo acusado foi amparada pela apreensão do entorpecente e da prova testemunhal produzida, não havendo, portanto, dúvida sobre a posse e a destinação mercantil, incidindo sobre a quantia em dinheiro apreendida com o entorpecente a pena de perdimento.

Isto considerando, passo à dosagem da pena.

Considerando o disposto no artigo 59, do Código Penal, e artigo 42 da Lei de Tóxicos, diante das circunstâncias pessoais favoráveis e não sendo expressiva a quantidade de entorpecente apreendido, possível seja fixada a pena-base no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Não havendo circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas, deve pena-base cominada ser reduzida em função do que disposto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06. Este dispositivo legal cuida da possibilidade de operar-se a redução da pena, quando se tratar de réu primário, de bons antecedentes, não integrante de organização criminosa e que não esteja dedicado ao comércio ilícito.

O acusado é primário, não ostenta condenação criminal anterior, não havendo indicação suficiente, por ocasião dos fatos, de que estivesse já dedicado à atividade criminosa, de tal modo que, também em função da pouca quantidade de entorpecente, deve a pena-base ser reduzida em 2/3 (dois terços), totalizando 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, em razão da situação econômica do acusado.

Diante da operada redução da pena inicialmente cominada, caracterizando a figura do tráfico privilegiado, devida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme entendimento que se consagrou no Colendo Supremo Tribunal Federal e Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Sobre isto, revendo entendimento consolidado anteriormente, com consequente cancelamento da Súmula nº 512, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça assentou que o tráfico de entorpecente, em sua forma privilegiada, não tem natureza hedionda. Segundo o decidido, apenas as modalidades de tráfico de entorpecentes definidas no artigo 33 caput e §1º, da Lei 11.343/06 seriam equiparadas aos crimes hediondos, enquanto referido delito na modalidade privilegiada apresentaria "contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa".

Além disto, destacou-se que, apesar da vedação constitucional e legal da concessão de graça e anistia e de indulto ao tráfico de entorpecentes, "os Decretos Presidenciais nº 6706/08 e 7049/09 beneficiaram os condenados pelo tráfico de entorpecentes privilegiado com o indulto, o que demonstra que os mencionados textos normativos inclinaram-se na corrente doutrinária de que o tráfico privilegiado não é hediondo".

Tal entendimento decorreu do posicionamento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em acórdão relatado pela Ministra Carmem Lúcia, observando-se que a decisão do legislador fora no sentido de que o agente deveria receber tratamento

distinto daqueles sobre os quais recairia o alto juízo de censura e de punição pelo tráfico de drogas e de que as circunstâncias legais do privilégio demonstrariam o menor juízo de reprovação e, em consequência de punição (HC 118.533/MS, 23/06/2016).

Acrescentou-se que, nem toda transação ilícita com drogas deve necessariamente submeter-se ao regime dos crimes hediondos, como a conduta de quem oferece droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem (art. 33, §3º, Lei 11.343/06), bem como a de quem, de forma episódica, pratica o denominado tráfico privilegiado (art. 33 §4º, Lei 11.343/06).

Nesta linha de raciocínio, consignou-se que o artigo 44 da Lei de Tóxicos, ao estabelecer que os crimes previstos nos arts. 33, caput e §1º, e 34 a 37 da Lei 11.343/06 "são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos", conferiu ao tráfico privilegiado (art. 33, §4º), tratamento especial ao que o legislador atribuiu ao caput e ao §1º do artigo 33, a reforçar a tese de que não se trata de delito hediondo.

Ainda segundo o que decidido, o conceito de hediondez é de todo incompatível ao de privilégio, conforme há muito vem decidindo o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no que diz com o homicídio qualificado-privilegiado, não se lhe aplicando o disposto na Lei 8072/90, afastando, portanto, a natureza hedionda. Concluiu-se que o julgamento proferido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, ainda que por seu Órgão Pleno, não tem efeito vinculante nem eficácia erga omnes. No entanto, a fim de observar os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, nos termos do artigo 927, §4º, do Código de Processo Civil, bem como de evitar a proliferação de decisões contraditórias nas instâncias ordinárias e também no âmbito daquele Egrégio Tribunal Superior, entendeu-se ser necessária a revisão da questão, com a determinação da revisão do entendimento anterior, estabelecendo-se a tese segundo a qual o tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada não é crime equiparado a hediondo.

Assim, cumpre seja a pena privativa substituída por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da pena cominada, a ser dirimida em execução, como também por uma pecuniária equivalente a 1 (um) salário mínimo.

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória e, com fundamento no artigo 33, caput, c.c. §4º da Lei nº 11.343/06, CONDENO o acusado JOSÉ THIAGO DE JESUS DOS SANTOS à pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 1 (um) ano e 8 (oito) meses, a ser dirimida em execução, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, corrigido desde a época do fato, como também de pena pecuniária equivalente a 1 (um) salário mínimo, operando-se ainda o perdimento da quantia apreendida com o entorpecente em favor da União, porque decorrente da ação ilícita, nos termos do disposto no artigo 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal, e artigo 63, da Lei nº 11.343/06.

Em caso de conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, esta deverá ser cumprida em regime prisional inicial aberto.

Diante da pena cominada, cumpre seja reestabelecida a liberdade provisória, com as medidas cautelares impostas, expedindo-se alvará de soltura clausulado em favor do acusado.

Oportunamente, promova-se o registro da condenação definitiva no sistema informatizado da serventia, comunicando-se o Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (I.I.R.G.D.).

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Rio Claro, 24 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA